

1500238-74.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... da confissão, a constatação do "tráfico-privilegiado", pela presença dos requisitos legais, e a substituição da privativa por restritivas de direitos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500238-74.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500238-74.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2058887/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 16520827 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2663/21/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2058887 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2058887 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2663/21/404 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE APARECIDO MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O acusado Felipe Aparecido Martins, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 01 de março de 2021, às 21:30 horas, na Rua Lourenço de Caprioli, nº 2-64 - Parque Olímpico, na cidade de Bauru-SP, o acusado foi surpreendido trazendo consigo 9 pinos de cocaína, para fins de tráfico.

Consta, também da exordial, que o acusado tinha em depósito, na própria residência,

um tijolo de maconha ou 867,68g, quatro porções fracionadas ou 68,15g, da mesma droga, 21 pinos ou 4 gr de cocaína e uma porção ou 16,5g à granel de cocaína. Boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição/apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação preliminar (fls. 27/36) e laudo definitivo (fls. 17/26).

Pelo crime, foi o acusado preso em flagrante.

Durante a análise do auto (fls. 80/84), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 126/128, foi determinada a notificação e citação do acusado.

O réu foi formalmente citado (fls. 155), tendo o defensor constituído ofertado defesa preliminar (fls. 141/147).

Na decisão de fls. 156/170, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 280/282, foi ouvida a testemunha Luiz Felipe Balbine. Depois, em novo ato processual da mesma natureza (fls. 313/315), foi ouvida a testemunha de acusação/defesa faltante e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 318/324 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, bem como, pela exasperação da pena-base, em razão da quantidade de droga apreendida, a constatação dos maus antecedentes, a valoração da confissão, e da agravante do “estado pandêmico”, o afastamento da benesse prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e a fixação do regime fechado.

Já a defesa constituída às fls. 333/341 pleiteou, em preliminar, pela nulidade da prova colhida, pela entrada em domicílio sem autorização, o que resultaria na improcedência, e, no mérito, pela desclassificação para o delito de consumo pessoal, pela absolvição por ausência de provas ou mesmo pela inexistência do elemento anímico – dolo -, ou a fixação da pena no mínimo legal, a valoração da confissão, a constatação do “tráfico-privilegiado”, pela presença dos requisitos legais, e a substituição da privativa por restritivas de direitos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição/apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação preliminar (fls. 27/36) e laudo definitivo (fls. 17/26).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O policial militar Luiz Felipe Balbine, na fase judicial (mídia SAJ) disse, em síntese, que tinham informação de que indivíduo de vulgo “Zóio” realizava o tráfico na região do Geisel. Afirmou que ele foi abordado na calçada, e, na busca pessoal, havia 9 pinos de cocaína, 40 reais e um celular. Informou que ele relatou que havia mais droga na casa dele, onde, sobre o guarda-roupa, em uma caixa de papelão, havia mais um tijolo de maconha, mais um pedaço médio de maconha, 21 pinos de cocaína, uma porção de cocaína a granel, duas facas com resquícios de maconha, balança de precisão e plástico filme. Esclareceu que o acusado era o “disciplina” do bairro. Mencionou que não havia mais ninguém na casa. Citou que a casa do acusado não tem acesso à casa do pai.

O policial militar Renato César Cherubim, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), disse, em síntese, que estavam em patrulhamento e um morador parou a viatura e denunciou pessoa de vulgo “Zóio”. Afirmou que conheciam o acusado e ele seria o “disciplina” da região. Informou que, em frente da residência, ele saía da casa, e, em busca pessoal, havia 9 pinos de cocaína, um celular e 41 reais no bolso. Esclareceu que não havia ninguém na casa, já que o pai é vizinho. Mencionou que não se recorda se as casas tinham entradas diferentes, porém, cada uma tinha um portão e números diversos.

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos, ainda que prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: “Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha”.

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Felipe sob o crivo do contraditório (mídia SAJ) disse, em síntese, que estava dormindo dentro de sua residência. Afirmou que se deparou com os policiais dentro da casa. Informou que não autorizou a entrada no imóvel, e que não faz parte de qualquer facção criminosa. Esclareceu que o entorpecente estava exposto quando da apreensão. Mencionou que morava no fundo, e que o acesso é único com a de uma casa alugada (que é da mãe). Citou que armazenava o entorpecente para pagar uma dívida com um traficante, em razão de seu vício.

A preliminar de violação do domicílio deve ser ultrapassada.

Segundo a defesa não houve "autorização" para os milicianos adentrarem à casa. De início, importante mencionar que a "denúncia anônima" (de que o acusado traficava no bairro) encontra fundamento de validade na própria Constituição Federal.

Com efeito, especialmente no crime de tráfico, a colheita de provas de pessoas "estranhas" aos quadros da segurança pública é temerária, até pelos altos índices de violência.

Por isso, a "delação apócrifa" serve para garantir a eficiência da repressão/investigação.

Nesse sentido o art. 144, §7º da Carta Magna: "§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades".

Não é outra a ideologia do art. 5º, §3º do CPP, preceito que encontra arrimo de validade no citado dispositivo da Constituição: "§ 3º Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito".

Assim, a "denúncia anônima", além de tornar despendiosa a identificação de seu autor (sob pena de desvirtuar o instituto e macular a eficiência dos órgãos da segurança pública), é instrumento "inicial", o qual deve ser "aprofundado", a fim de que não exista qualquer ilegalidade.

Nesse sentido:

E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - RECURSO ORDINÁRIO - MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" -

LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - DELAÇÃO ANÔNIMA - ADMISSIBILIDADE - CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DOS REQUISITOS LEGITIMADORES DE SEU ACOLHIMENTO - DOUTRINA - PRECEDENTES - PRETENDIDA DISCUSSÃO EM TORNO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - PRECEDENTES - RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. PERSECUÇÃO PENAL E DELAÇÃO ANÔNIMA - As autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução (penal ou disciplinar), apoiando-se, unicamente, para tal fim, em peças apócrifas ou em escritos anônimos. É por essa razão que o escrito anônimo não autoriza, desde que isoladamente considerado, a imediata instauração de "persecutio criminis". - Nada impede que o Poder Público, provocado por delação anônima ("disque-denúncia", p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, "com prudência e discricção", a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da "persecutio criminis", mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas. - Diligências prévias, promovidas por agentes policiais, reveladoras da preocupação da Polícia Judiciária em observar, com cautela e discricção, notadamente em matéria de produção probatória, as diretrizes jurisprudenciais estabelecidas, em tema de delação anônima, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" - Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação "per relationem", que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. INADMISSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE "HABEAS CORPUS" - O processo de "habeas corpus", que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes. (STF, 2ª Turma, RHC 117988 / RS - RIO GRANDE DO SUL, relator ministro Gilmar Mendes, relator para o acórdão ministro Celso de Mello, julgado em 16/12/2014) De outro lado, o tráfico é delito permanente e multinuclear que admite flagrante a qualquer tempo.

Ademais, a mais alta Corte do país recentemente assentou a constitucionalidade da mesma hipótese, tendo proferido a seguinte tese:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticado" (STF, Plenário, RE 603616/RO, relator min. Gilmar Mendes, julgado em 04 e 05/11/2015, em repercussão geral)".

As fundadas razões no caso concreto estão delineadas pela autorização do acusado Felipe mencionada pelos policiais, suspeita confirmada pela variedade de droga apreendida, além de petrechos para o tráfico de drogas, como facas e papel filme. Importante salientar que a negativa de "autorização" mencionada pelo acusado restou solteira nos autos.

Inclusive, na resposta à acusação, nem sequer a tese foi aventada, em muito, pela ausência de comprovação da alegação.

Aliás, não é outro o entendimento do Tribunal da Cidadania:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

2. O Juízo singular ressaltou que o recorrente trazia consigo cinco porções de maconha quando foi abordado pela autoridade policial e afirmou que havia mais entorpecentes guardados em sua residência. Essa circunstância motivou o ingresso no domicílio do réu, onde se apreenderam mais 103 buchas de maconha.

3. Com base nessa moldura fática, constato que a entrada dos milicianos na residência do acusado estava calcada em diligências prévias que apontavam o seu envolvimento com o tráfico de drogas, a denotar motivos idôneos para o ingresso forçado.

4. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal.

5. Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Juízo singular ressaltou o fundado risco de reiteração delitiva, diante do registro de outra ação penal em desfavor do réu, em que se apura a prática de delito de mesma natureza, e de sua anterior prisão em flagrante pelo suposto cometimento de crime de roubo, oportunidade em que foi beneficiado com a concessão de liberdade provisória. Além disso, foi destacada a quantidade de entorpecente apreendido em poder do réu (220 g de maconha), circunstância que reforça a necessidade de sua custódia cautelar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

6. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).

7. Recurso não provido.

(STJ, 6ª Turma, RHC 95205 / MG, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 21/06/2018)

Portanto, não há qualquer ilegalidade, de modo que a preliminar deve ser rejeitada. Pela prova colhida, a meu ver, de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

De início, a desclassificação para o delito de consumo pessoal não é possível.

A forma de acondicionamento do entorpecente, os petrechos apreendidos, a variedade de drogas, denotam que o comércio espúrio era realizado no local.

Ademais, o acusado é portador de maus antecedentes e reincidente pela mesma prática delituosa (fls. 54/60 e 62/63), circunstâncias que sugerem a prática do tráfico, nos termos do art. 28, §2º da Lei nº 11.343/06.

Depois, os policiais foram categóricos em afirmar que o acusado já era conhecido nos meios policiais, o que restou delineado pelas condenações pretéritas, bem como, pela "denúncia anônima" como traficante no bairro, exercendo, ainda, a 'função' de "disciplina".

Em arremate, o acusado foi abordado ainda na calçada, quando portava parte da droga (cocaína), bem como um celular, e ainda dinheiro em notas miúdas.

Sob outro vértice, o elemento anímico (dolo) restou evidenciado pelo acusado saber que armazenava a droga.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Sob outro aspecto, deve o acusado Felipe permanecer custodiado.

A natureza de parte do entorpecente - cocaína - conforme adiante se verá é perniciososa.

Ademais, o acusado possui dois feitos (ambos por tráfico), com condenações transitadas em julgado (fls. 54/60 e 62/63, feito nº 0027457-08.2011.8.26.0071 e 3004623-86.2013.8.26.0071).

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACAUTELADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento este chancelado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos.

2. Constrangimento ilegal não configurado, pois, conforme exegese teleológica do art. 282, caput, incisos I e II, c.c. as cautelares pessoais não prisionais estatuídas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, contornados pela sistemática estatuída na Lei n. 12.403/11 e sob a égide da proporcionalidade (formal e material), afigura-se suficiente e adequada, conforme as peculiaridades do caso concreto, a imposição ao acautelado da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e uso de estupefacientes quando este confessa, no bojo da persecução criminal, ser usuário (dependente químico) e ter praticado o delito sob os efeitos de tais substâncias, as quais potencializam - caso não evitadas - o risco no cometimento de novas infrações.

3. Na hipótese, a necessidade e adequação das medidas não prisionais em testilha foram justificadas pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, permeadas pela confissão da prática delitiva de suposto furto "motivada pela fissura da droga" e, conforme evidenciado na audiência de custódia, consulta ao SISP revela que este teve outras duas ocorrências policiais anteriores pela prática da mesma espécie de crime, malgrado ser tecnicamente primário.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 395336 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 24/04/2018)

Passo à fixação da pena.

Réu Felipe Aparecido Martins

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedente criminal (feito nº 0027457-08.2011.8.26.0071).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Depois a natureza e variedade das drogas (cocaína e maconha), denotam a necessidade de exasperação da pena em $\frac{1}{4}$, perfazendo 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Isto por que, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que a natureza, bem como a quantidade de drogas, são circunstâncias preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a

conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, o acusado é reincidente específico (feito nº 3004623-86.20138.26.0071), o que permite a agravação em maior escala.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE TRÁFICO. NULIDADE. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. LEITURA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 3. AGRAVAMENTO DA PENA. PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 4. CAUSAS DE AUMENTO. CRIME PERTO DE ESCOLA E COM ADOLESCENTE. PLEITO DE DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

3. As circunstâncias judiciais bem como as agravantes e atenuantes não possuem patamares fixos de aplicação da pena, ficando o quantum de elevação a critério do magistrado, desde que observada a razoabilidade. A jurisprudência, visando a balizar um critério razoável, assentou que seria adequada uma elevação que não fosse superior 1/6 (um sexto). No entanto, cuidando-se de réu multirreincidente ou reincidente específico, revela-se escorregia a agravação da pena em patamar maior, uma vez que devidamente motivada em elemento concreto dos autos. Portanto, não há qualquer ilegalidade no agravamento da pena em 1/5 (um quinto) em virtude de o réu ser reincidente específico.

(...)

(STJ, 5ª Turma, HC 282148 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03/05/2016)

Ainda na fase intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da

participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na mesma fase, não ocorreu a atenuante da confissão.

Ocorre que o acusado apenas disse que foi surpreendido pelos policiais já dentro de sua residência.

Não mencionou, assim, toda a dinâmica delitiva, quando teria sido abordado antes, na calçada em frente do imóvel.

Por isso, as circunstâncias delitivas não foram inteiramente delineadas pelo acusado.

Portanto, a pena deve ser agravada em 1/5, atingindo 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentas e cinquenta) diárias.

Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o acusado é reincidente específico.

Nem se fale que haveria bis in idem na utilização da reincidência na segunda fase e na derradeira, por que o instituto é utilizado de maneira diversa.

Na intermediária, a reincidência é fator para agravar a pena, já que sempre deve agravar a reprimenda, nos estritos termos do art. 61 "caput" do Código Penal, e, ressalvadas as hipóteses legais.

Já na última fase é pressuposto para negar o redutor previsto no art. 33, §4º da lei 11343/06, salientando-se que os requisitos lá plasmados são cumulativos.

A variação da diminuição na minorante é cotejada com fatores diversos, tais como quantidade e natureza da droga (quando não utilizados na primeira fase), as circunstâncias da ocorrência, a personalidade do acusado, ou seja, de modo geral, o próprio art. 42 da lei 11343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, na terceira fase da dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que os acusados se dedicariam a atividades delituosas, especialmente ao narcotráfico, motivo pelo qual não há falar em bis in idem.

2. A simples reincidência dos réus já é elemento suficiente para, por si só, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse benefício aos acusados reincidentes.

3. Se ainda não houver decorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior é geradora de reincidência, independentemente de ela ser ou não pela prática do mesmo delito.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1382648 / SP, por unanimidade, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/06/2019)

Em seguida, além de ser portador de maus antecedentes, a variedade de droga (maconha e cocaína) também impede a benesse.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES ALIADAS ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.

1. Para a incidência do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a Corte de origem concluiu que o agravante se dedica à atividades criminosas, em razão da quantidade e variedade da droga apreendida aliada às demais circunstâncias do delito, notadamente o fato de ter sido flagrado em conhecido ponto de venda de drogas portando um rádio comunicador, anotações e certa quantia em dinheiro, [não] não fazendo jus à benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

3. É de se destacar que o fato de a lei não estabelecer critérios objetivos para a incidência do citado benefício não impede que o julgador, no exame do caso concreto, possa preencher a lacuna legal, não havendo que se falar, assim, em fundamentação inidônea.

4. Para afastar a conclusão do Tribunal local no sentido de que o agravante se dedica a atividades criminosas, seria necessário a este Sodalício aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em Recurso Especial, conforme Súmula n. 7/STJ.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível avaliar a quantidade e a natureza da droga para aumentar a pena-base, bem como para afastar a benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas na terceira fase da dosimetria, desde que aliadas à outras circunstâncias do delito que evidenciem a dedicação à atividade criminosa, sem ofensa ao princípio do non bis in idem.

(...)

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1259578 / SP, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 19/06/2018)

Assim, a pena atingida na segunda fase é a definitiva.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

A quantidade da pena privativa de liberdade, os maus antecedentes e a reincidência impedem a substituição da reprimenda por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I a III do Código Penal.

Fixo o regime inicial fechado.

O réu Felipe é reincidente específico, além de portador de maus antecedentes, pela mesma prática delitiva.

Além disso, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação

demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e, desta feita, CONDENO o acusado Felipe Aparecido Martins, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) diárias, em regime inicial fechado, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Nego ao acusado Felipe o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados. Considerando o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 33/34. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Quanto ao aparelho celular e entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, tributo cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a gratuidade judiciária, outrora deferida às fls.

156/170.

P.R.I.C.

Bauru, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA